

1525273-67.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1525273-67.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1525273-67.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON DAS GRAÇAS ANDRADE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

JEFFERSON DAS GRAÇAS ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, porque, segundo apurado, no dia 16 de outubro de 2021, por volta das 13h30min, em época de calamidade pública pela Covid 19, na Rua Professor Cosme Deodato Tadeu, nº 100, Lajeado, nesta cidade e comarca, qualificado a fls. 12, trazia consigo 63,7 gramas de tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como MACONHA, acondicionada em 28 invólucros plásticos; 59 gramas de COCAÍNA, acondicionada em 117 invólucros plásticos e 121 miligramas de tricloroetileno, popularmente conhecido como LANÇA-PERFUME, acondicionado em 11 frascos de vidros, substâncias capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A denúncia foi recebida, o réu foi citado e notificado e apresentou resposta à acusação.

Após a manutenção do recebimento da denúncia, em sede de audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidos dois policiais e o réu foi interrogado. (fls. 162 e 173/179).

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pugnou, em suma, pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

Já a Defesa pleiteou, pela absolvição do réu por insuficiência probatória, ou ainda com base no disposto no art. 386, II, do Código de Processo Penal em razão do "comprometimento da materialidade delitiva", alegando, em suma que foram

apreendidas drogas no chão e em posse do acusado e que tais substâncias não foram devidamente identificadas e separadas, não se tendo assim conhecimento sobre a efetiva quantidade de drogas encontradas com o réu, e em caso de eventual condenação buscou a desclassificação do crime de tráfico para o crime previsto no art. 37 da Lei 11.343/06, a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da confissão e sua compensação com a agravante da reincidência, o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal e ainda a aplicação fixação de regime diverso do fechado para o cumprimento de sua pena, com aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há que se falar em quebra da cadeia de custódia, uma vez que segundo os policiais as drogas foram apreendidas na posse do indiciado que as dispensou durante sua fuga, e foram objeto de perícia, conforme laudo de constatação provisória, do qual consta inclusive foto e números dos lacres, além disso há cópia da requisição do laudo pericial, da qual consta os números dos lacres, tudo a indicar que a cadeia de custódia foi preservada na coleta, acondicionamento e armazenamento.

Sobre o tema, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça: Apelação Criminal TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Preliminar de nulidade da prova produzida. Prisão realizada por guardas civis. Réu em situação de flagrância. Ausência de materialidade por vício na cadeia de custódia. Não acolhimento. Substâncias devidamente lacradas e perfeitamente relacionadas ao réu no momento da realização do laudo definitivo. No mérito, conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o uso. Prisão em flagrante delito com considerável quantidade de drogas. Depoimentos de testemunhas.

Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Pena. Redução. Regime bem aplicado. Provimento em parte.

(Apelação Criminal nº 1501126-67.2019.8.26.0544, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, 10ª Câmara Criminal, j. 15/06/2020)

Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Prisão em flagrante. Conversão em preventiva.

Alegada nulidade das provas colhidas. Inocorrência. "(...) a mera alegação de ilicitude das provas colhidas, por suposta 'quebra da cadeia de custódia' em razão de não ter sido fielmente respeitada 'a exigência de isolamento, fixação, coleta, acondicionamento e transporte dos entorpecentes apreendidos, em afronta ao disposto no artigo 158-A, § 1º e 158- C, II, III, IV e V, ambos do Código de Processo Penal', sem a demonstração concreta de ter havido, na hipótese, efetiva violação e/ou adulteração dos elementos de prova, não autoriza o reconhecimento da imprestabilidade deles, seja porque há presunção de validade e legitimidade dos atos praticados por funcionários públicos, seja porque uma análise mais aprofundada a respeito do eventual desrespeito às formalidades previstas na norma processual penal para a obtenção das provas do crime e das seus reflexos na validade delas como elementos de convicção só é passível de ser feita pelo duto juiz, durante a instrução do processo. (...) " Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 2164760-34.2020.8.26.0000, rel. Des. Mário Devienne Ferraz, 1ª Câmara Criminal C, j. 31/08/2020).

No mérito propriamente dito, não obstante as alegações da Defesa, analisando as provas colhidas nos autos, há provas suficientes para a condenação do acusado.

Os dois policiais ouvidos em juízo afirmaram que se dirigiram ao local dos fatos para atender uma ocorrência de um suposto roubo e ao se aproximarem de uma passarela viram três indivíduos em atitude típica de tráfico de drogas e se aproximaram, neste instante o réu tentou fugir mas acabou sendo preso. O réu trazia consigo uma mochila dentro da qual várias porções de drogas foram encontradas e durante a tentativa de fuga, algumas porções das drogas caíram ao chão e também foram recuperadas.

Eles afirmaram, ainda, que os outros dois indivíduos não tentaram fugir e também foram abordados, sendo que com um deles havia uma porção de entorpecentes e com o outro nada de ilícito foi encontrado e que diante disso, os três foram então conduzidos ao Distrito Policial onde foi elaborado o boletim de ocorrência.

O réu por sua vez, negou a prática do crime, disse que realmente estava no local onde foi apreendido pelos policiais e que é dependente químico, usuário de "crack" e ali estava para como "olheiro", ou seja, para alertar os traficantes sobre a eventual aproximação da polícia e que no dia dos fatos, o verdadeiro traficante foi por ele alertado sobre a chegada da polícia e conseguiu fugir abandonando as drogas e o dinheiro, próximo de um rio existente no local.

A versão do acusado, no entanto, não foi comprovada por outras provas e não é crível já que não faz sentido algum que o "verdadeiro" traficante, devidamente avisado da aproximação da polícia fuja da apreensão e deixe para trás seu ganha pão, ou seja, as drogas e o dinheiro.

Veja-se, ademais, que o acusado nada disse sobre os outros dois indivíduos que foram presos também e a Defesa, sequer os arrolou para que eventualmente pudessem ser ouvidos e confirmar a versão do réu.

Desse modo, a tese de Defesa não veio provada nos autos, não bastando a mera alegação do réu, como quer fazer crer o combativo defensor, nos exatos termos do que dispõe o art. 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: "A prova da alegação incumbirá a quem a fizer..."

Portanto, não há que se desclassificar a conduta do acusado para o delito previsto no art. 37 da Lei de Drogas.

Em contrapartida, os depoimentos dos policiais convergem em mesmo sentido e os dois foram uníssomos em afirmar, em ambas as oportunidades em que foram ouvidos e relataram que as drogas apreendidas estavam dentro da mochila que era de propriedade do réu que fugiu ao perceber a aproximação da polícia.

A materialidade do delito em questão restou comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão das drogas, laudo pericial de fls. 158/160, com resultado POSITIVO para os três tipos de entorpecentes apreendidos.

É de asseverar, ainda, que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos.

Não é suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de agentes policiais. Ressalte-se que a diligência policial promovida neste processo decorreu de patrulhamento que realizavam pela região conhecida como sendo ponto de venda de drogas. sem que haja qualquer indício que qualquer perseguição pelos policiais houvesse em relação ao acusado.

Nesse sentido: "Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Por conseguinte, é idônea a prova oral produzida pela acusação.

Diante de todo o conjunto probatório formado nos autos, ficou plenamente atestado que a droga encontrada dentro da mochila e no chão, no caminho feito pelo réu durante a tentativa de fuga, estavam na posse do acusado e realmente se destinavam ao consumo de terceiros.

Ressalta-se, ainda, que a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, o local em que o réu estava, por ele mesmo reconhecido como local conhecido pela polícia como sendo ponto de venda de drogas, bem como o

dinheiro, com ele encontrados, já são suficientes para caracterizar o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado: "PROVA CRIMINAL - Tóxico - Tráfico - Quantidade da droga apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induzem à certeza de destinação ao comércio - Recurso não provido". (Relator: Lustosa Goulart - Apelação Criminal n.º 159.552-3 - São Paulo - 05.05.94).

Dessa forma, considerando-se que o réu não produziu prova alguma capaz de infirmar os fatos que lhe são atribuídos na denúncia, merece total acolhimento a pretensão punitiva.

Caracterizada, portanto, a infração penal a condenação é medida que se impõe. Dessa forma, passo a dosar a pena.

O réu é reincidente, já tendo sido condenado definitivamente por crime de roubo, autos de execução 0012496-22.2019.8.26.0996, (fls. 68), o que será levado em consideração na segunda fase da aplicação da pena.

Além disso possui outros dois processos de execução cujas penas foram extintas pelo cumprimento há mais de 05 anos, e outro cujo pena se extinguiu em 05/08/19, conforme se verifica das folhas de antecedente juntadas a fls. 53/62. Tais fatos, serão aqui considerados como maus antecedentes e nos permitem aumentar a pena base em 1/4, chegando-se a 6 anos, 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, já que não lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Não há que se falar em desconsideração das condenações acima apontadas apenas e tão somente pelo decurso do tempo já transcorrido, de fato, se por um lado elas não podem mais serem consideradas como agravantes em razão do disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal, fato é que nada impede de considera-las como maus antecedentes, já que demonstram a personalidade criminosa do acusado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

STJ- "condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes" (HC 456891/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02.10.2018).

E ainda, conforme precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal, "não constitui ilegalidade o fato da sentença considerar os antecedentes criminais e outras circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do Código Penal, aumentando, depois, a pena base, em razão da reincidência" (HC nº 1.990, Rel. Min. Carlos Velloso, DJU de 22.09.95, p. 30.591).

"Apesar de desaparecer a condição de reincidente, o agente não readquire a condição de primário, que é como um estado de virgem, que, violado, não se refaz. A reincidência é como o pecado original: desaparece, mas deixa sua mancha, servindo, por exemplo, como antecedente criminal" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 238).

Na segunda fase, há que se reconhecer a agravante da reincidência atestada nos autos, e também que o crime foi cometido em situação de calamidade pública tendo em vista a pandemia que assola o país por conta do coronavírus - COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020.

Neste ponto, respeitadas as posições em contrário, para esta magistrada, o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal.

Neste sentido, já se manifestaram nossos Tribunais: "Na segunda fase, o crime foi praticado durante o período de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879/20. Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos" (TJ-SP - PR: 15078616020208260228 SP 1507861- 60.2020.8.26.0228, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/07/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:

21/07/2020).

E ainda: "(...) Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência" (Apelação Criminal 1509419- 67.2020.8.26.0228. Rel. Edison Brandão. Quarta Câmara de Direito Criminal TJSP. J. 26/01/2021).

"Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias." (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camilo Léllis, 4ª Câmara Criminal, j. 09/0).

A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo Autos nº 1509419-67.2020: "O acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença", escreveu o magistrado em seu voto. "De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência."

"O Decreto Legislativo nº 06/2020, do Congresso Nacional, e o Decreto Estadual nº 64.879/2020, reconheceram a situação de calamidade pública resultante da pandemia concernente ao novo coronavírus. E o reconhecimento de tal circunstância motiva a incidência de referida agravante.

Ora, diante de tal situação de calamidade pública, a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada, a fechar-se em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a cerrar portas. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate à pandemia.

Desse modo, toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida como calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda.

Pese tenha inteligência no sentido de emprestar uma interpretação mais restritiva para a norma prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, a Câmara assentou entendimento pela incidência da circunstância agravante numa situação como

a dos autos.

A compreensão é de, com o estado de calamidade provocado pela ação do coronavírus (declarado pelo Decreto Legislativo 06/2020, do Congresso Nacional), "a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada a ficar em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a fechar. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate da pandemia.

Desse modo toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida com calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda" (Apelação nº 1512223-08.2020.8.26.0228, rel. Des. Hermann Herschander).

"Não se exige na linha do que penso - que o agente se aproveite especificamente do quadro de pandemia para a realização do crime, ou seja, que essa situação tenha facilitado, de alguma maneira, a ação criminosa. É suficiente, para a incidência da circunstância agravante, que o crime tenha sido cometido durante o período de calamidade pública critério temporal puramente objetivo. Orientação que acompanho nesta oportunidade, em atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC nº 142.585, rel. Min. Celso de Mello).

STJ - "(...) impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art. 61, II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda população do Município, colocando em risco a saúde pública" (HC nº 584.871, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04.06.2020, DJe 08.06.2020).

TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL (...) Afastamento da agravante prevista no art. 61, II, 'j', do CP Descabimento Crime cometido durante o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19 Inexigência legal de outros requisitos para caracterização da agravante (...) Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1510315-13.2020.8.26.0228, Rel. Camilo Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, J. 16.10.2020). Com idêntico raciocínio: Apelação nº 1507788-88.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 21.09.2020; Apelação nº 1513982-07.2020.8.26.0228, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Freitas Filho, j. 19.01.2021.

Des. Fátima Gomes - 9ª Câmara: "Com efeito, na alínea "j" do inciso II do art. 61 do Código Penal, encontra-se previsão para a agravação da pena diante de circunstâncias que representem o aproveitamento por quem realiza o crime da existência de uma situação de perigo comum. Cabe notar não ser necessário que o sujeito crie a situação de perigo, mas que apenas a aproveite. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias.

Na situação especial, o apelante aproveitou-se de acontecimentos de especial relevo para a vida da população. O acontecimento e seus efeitos maléficos devem, obrigatoriamente, ser conhecidos por quem deles conscientemente aproveita-se. Nesse sentido:

"Essa circunstância implica maior gravidade do injusto, de modo a agravar o desvalor da ação, dado que a produção do resultado delituoso se revela mais provável. É necessário que o agente tenha se aproveitado, de modo consciente e voluntário, da ocasião ou do momento particularmente difícil em que se encontra a vítima, com o fim de dificultar sua defesa. Tal agravante também se fundamenta em razões político-criminais, pois o agente pode prevalecer-se das circunstâncias não apenas para debilitar a defesa da vítima, mas também para facilitar sua

impunidade." (PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal: Jurisprudência, Conexões Lógicas com os Vários Ramos do Direito. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 335).

Assim, referida agravante tem natureza objetiva, estampada no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal e, diante da notória calamidade pública gerada pela pandemia do vírus covid-19, mostra-se absolutamente desarrazoada a pretensão defensiva de afastá-la.

Assim a pena deve ser exasperada em mais 1/5 chegando-se ao patamar de 7 anos, 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Na terceira fase, além da reincidência atestada nos autos, o réu possui outras condenações definitivas o que demonstra com clareza que se dedica a atividades criminosas e assim sendo, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não há que reduzir a pena do acusado.

Não há que se falar, por fim, na ocorrência de bis in idem ao se considerar a reincidência para agravar a pena e, ao depois, negar a aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido autos de apelação nº 1510566-31.2020.8.26.0228,: "...na aplicação do preceito em foco, o Juiz há de verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena, não se podendo falar em bis in idem por ter sido a reincidência considerada para aumentar as sanções e também impedir a incidência do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, pois a aplicação de tal dispositivo exige a ocorrência simultânea de todas as condições mencionadas, ou seja, ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização criminosa, o que não é o caso do acusado".

"Não há que se falar em bis in idem mas sim em cumprimento dos efeitos lógicos, legalmente previstos, decorrentes de um mesmo instituto jurídico a reincidência quando foi agravada a sanção do paciente na segunda etapa da dosimetria, dado o reconhecimento da agravante do art. 61 do CP, e deixou-se de fazer incidir a causa especial de diminuição da pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão da não primariedade do paciente" (HC 118403/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 15.12.2009)." (Apel. Crim. Nº 990.10.184009-0, 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tristão Ribeiro).

"O agravamento da pena pela reincidência também está correto e decorre de expressa determinação legal. Não ocorreu bis in idem. Não é raro que uma mesma circunstância reflita em mais de uma direção. O reincidente, v.g., não tem direito a sursis, por expressa disposição legal. Não obstante, o magistrado é obrigado a exacerbar sua pena, porque a reincidência também é agravante. Seguindo o mesmo raciocínio, no caso ora em exame, não aplicável a causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, dada a recidiva, a qual também é usada para agravar a pena, por determinação legal." (Rev. Crim. NCrim. Nº 990.09.160794-0, 6º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Eduardo Pereira).

No mesmo sentido é a Jurisprudência dos Tribunais Superiores: "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. MINORANTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 3. Ausência de bis in idem na condenação que aplica a agravante de reincidência e afasta a causa de diminuição na terceira fase de fixação da pena, por ausência de atendimento aos requisitos para a aplicação da privilegiadora. 4. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC 191.580 2ª Turma do STF Rel. Min. Edson Fachin j. 16/11/2020).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. CONFISSÃO PARCIAL NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. MINORANTE DO § 4º NÃO APLICADA EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não configura bis in idem. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC 558867/SP 5ª Turma do STJ Rel. Min. Joel Ilan Parcionik j. 02/2/2021).

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra o réu para CONDENÁ-LO à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 750 dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo, já que não há nos autos provas da situação econômica do acusado, por estar incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como sua reincidência, o réu cumprirá a pena em regime inicial fechado.

No mais, não poderá apelar em liberdade notadamente porque, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou.

Ademais, remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, já que ainda persistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, que deve ser mantida, notadamente, para a garantia da ordem pública, já que este delito é o que sustenta várias organizações criminosas que com o dinheiro adquirido com a venda de entorpecentes se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos.

Em cumprimento ao art. 316, do CPP, já com a nova redação, dou por revisada a decisão que determinou sua prisão preventiva.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD. Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06.

Se o caso, autorizo a destruição de toda drogas apreendidas, oficiando-se neste sentido.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA